

1500239-79.2021.8.26.0555

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Crimes do Sistema Nacional de Armas

Magistrado: Antonio Benedito Morello

Comarca: São Carlos

Foro: Foro de São Carlos

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 13/12/2022

... ainda que mais grave, como exemplo um roubo, estupro, tráfico, etc., a reincidência não seria pelo mesmo crime e a substituição poderia acontecer, nos termos do artigo 44, § 3º, do CP.

Assim, a despeito de a reincidência ter se operado pela prática do mesmo crime, volto a dizer cometido o primeiro há mais de quatorze anos, é socialmente recomendável que o réu cumpra a pena aqui ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São Carlos

Foro de São Carlos

1ª Vara Criminal

Rua Conde do Pinhal, 2061, São Carlos - SP - cep 13560-648

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1500239-79.2021.8.26.0555 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500239-79.2021.8.26.0555

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Crimes do Sistema Nacional de Armas

Autor:

Justiça Pública

Réu:

CARLOS ALEXANDRE GONÇALVES DA ROCHA

Prioridade Idoso

Justiça Gratuita

VISTOS

CARLOS ALEXANDRE GONÇALVES DA ROCHA, com dados qualificativos nos autos, foi denunciado como incurso nas penas do artigo 14, "caput", da Lei nº 10.826/03, e no artigo 29, "caput", c. c. o § 4º, inciso V, da Lei nº 9.605/98, e na forma do artigo 69, do Código Penal, porque no dia 28 de agosto de 2021, por volta das 18h00, no interior da área de preservação permanente do imóvel rural localizado no Km 166 da SP 215 (Rodovia Luiz Augusto de Oliveira), nesta cidade e comarca, juntamente com João Gilberto Cinicola, portava, detinha e transportava e mantinha sob guarda arma de fogo e munição, de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, consistente em uma espingarda calibre 32, marca Bereta, nº 26416, com cinco cartuchos íntegros e dois deflagrados. Consta ainda que nas mesmas circunstâncias de tempo e local, juntamente com João Gilberto Cinicola, e utilizando-se a arma descrita, caçou e matou espécie da fauna silvestre

nativa, consistente em uma capivara, igualmente sem a devida permissão, licença ou autorização da autoridade competente, no interior de uma unidade de conservação (fls. 144/147).

Foi preso e autuado em flagrante, obtendo a liberdade provisória (fls. 98/99). Recebida a denúncia (fls. 156), o réu foi citado (fls. 164) e respondeu a acusação através da Defensoria Pública (fls. 167). Na instrução foi ouvida uma testemunha de acusação e o réu interrogado (fls. 230/231 e 260). Em alegações finais o dr. Promotor de Justiça opinou pela condenação dos réus nos termos da denúncia (fls. 260). A Defesa, quanto ao crime ambiental, pediu a exclusão da ilicitude nos termos do artigo 37, I, da Lei 9.605/98, porque o abate ocorreu para saciar a fome do agente; questionou a ausência de comprovação da materialidade porque o animal não foi periciado para constatar se seria espécie da fauna silvestre, porquanto poderia se tratar de “javaporco” e não de capivara; e quanto ao porte de arma, deve ser reconhecido que foi justamente o meio para a prática da infração ambiental, se esta for reconhecida, devendo ser considerado crime único pelo princípio da consunção. E, em caso de condenação, pela aplicação das penas mínimas, com regime aberto e substituição da pena restritiva de liberdade por restritiva de direito (fls. 260).

É o relatório.
D E C I D O.

O réu Carlos Alexandre Gonçalves da Rocha, que aqui está sendo julgado, juntamente com João Gilberto Cinicola, que obteve o benefício de ANPP (fls. 236/246), foi surpreendido por policiais florestais portando espingardas e quando tinham abatido um animal, que consta ser uma capivara.

Não deixa de ter razão o Defensor Público quando questiona a ausência de prova da materialidade, porque o animal abatido não foi submetido a exame pericial para ter a constatação de se tratar de animal silvestre.

Não supre a falta do exame a foto de fls. 27, porque o que se vê é o animal abatido, sem o couro ou a pelagem, impossibilitando saber a espécie. E se havia a possibilidade do exame direto, não poderia este ser substituído pelas declarações do réu e das testemunhas, como aconteceu (artigo 158 do CPP).

Mas, mesmo que reconhecido que o animal abatido seja uma capivara, animal da fauna silvestre, entendo que na espécie deve ser reconhecida a atipicidade à conta da insignificância do objeto da ação praticada.

Aqui, mesmo que não tenha sido demonstrada a causa de exclusão da ilicitude prevista no artigo 37, I, da Lei 9.605/98, porque prova alguma foi produzida pela Defesa do estado de necessidade do réu, a verdade é que o abate ocorreu para fins de alimentação. É muito comum pessoas simples e de pouco recurso, buscar abater capivaras para servir de alimento, “mistura” como disse o réu. E essa previsão legal, afastando a criminalidade do fato, constitui um modo de relativizar a própria lei para casos em que a ação do réu não seja impactante, com aqui aconteceu.

E essa espécie de animal, capivara, que se multiplica com facilidade, tem sido um transtorno para a população, do campo pela destruição das lavouras, como também com invasão delas nos centros urbanos, trazendo doenças, por ser este animal hospedeiro de carrapatos.

E justamente por esse comportamento nocivo, existe a previsão de exclusão da criminalidade (artigo 37, incisos II e IV, da Lei 9.606/98), e órgãos públicos tem constantemente autorizado o abate da espécie em determinadas ocasiões, revelando não se tratar de animal com risco de extinção.

Assim, no presente caso, em relação ao crime ambiental, deve ser reconhecido e aplicado o princípio da insignificância.

Esse princípio foi introduzido por CLAUS ROXIN, segundo o qual "...o Direito Penal, por sua natureza fragmentária, só vai até onde seja necessário para a proteção dos bens jurídicos. Não deve ocupar-se de bagatelas...".

Doutrina CLEBER MASSON: "O princípio da insignificância surgiu no Direito Romano, porém limitado ao direito privado. Invocava-se o brocardo de minimus non curat praetor, ou seja, os juízes e tribunais não devem se ocupar de assuntos irrelevantes. Este princípio foi incorporado ao Direito Penal somente na década de 1970, pelos estudos de Claus Roxin. Também conhecido como criminalidade de bagatela, sustenta ser vedada a atuação penal do Estado quando a conduta não é capaz de lesar ou no mínimo de colocar em perigo o bem jurídico tutelado pela norma penal". E conclui mais adiante ao tratar da sua natureza jurídica: "O princípio da insignificância é uma causa de exclusão da tipicidade. Sua presença acarreta na atipicidade do fato. Com efeito, a tipicidade penal é constituída pela união da tipicidade formal com a tipicidade material. Na sua incidência, opera-se tão somente a tipicidade formal (juízo de adequação entre o fato praticado na vida real e o modelo de crime descrito na norma penal). Falta a tipicidade material (lesão ou perigo de lesão ao bem jurídico). Em síntese, exclui-se a tipicidade pela ausência de sua vertente material. Como corolário da atipicidade do fato, nada impede a concessão de ofício de habeas corpus pelo Poder Judiciário, quando caracterizado o princípio da insignificância. Além disso, o transido em julgado da condenação não impede seu reconhecimento" (CÓDIGO PENAL COMENTADO, 6ª EDIÇÃO, 2018, Ed. Método, página 7 - destaque do próprio texto).

Oportuno transcrever importante lição do sempre lembrado Ministro Francisco de Assis Toledo: "Segundo o princípio da insignificância, que se revela por inteiro pela sua própria denominação, o direito penal, por sua natureza fragmentária, só vai até onde seja necessário para a proteção do bem jurídico. Não deve ocupar-se de bagatelas. Assim, no sistema penal brasileiro, por exemplo, o dano do art. 163 do Código Penal não deve ser qualquer lesão à coisa alheia, mas sim aquela que possa representar prejuízo de alguma significação para o proprietário da coisa; o descaminho do art. 334, § 1º, d, não será certamente a posse de pequena quantidade de produto estrangeiro, de valor reduzido, mas sim a mercadoria cuja quantidade ou cujo valor indique lesão tributária, de certa expressão para o Fisco; o peculato do art. 312 não pode estar dirigido para ninharias como a que vimos em um volumoso processo no qual se acusava antigo servidor público de ter cometido peculato consistente no desvio de algumas amostras de amêndoas; a injúria, a difamação e a calúnia dos arts. 140, 139 e 138, devem igualmente restringir-se a fatos que realmente possam afetar significativamente a dignidade, a reputação, a honra, o que exclui ofensas tartamudeadas e sem conseqüências palpáveis; e assim por diante" (PRINCÍPIOS BÁSICOS DE DIREITO PENAL, Ed. Saraiva, 5ª edição, pág. 133).

Ao tratar do assunto, CEZAR ROBERTO BITENCOURT ensina: "A tipicidade penal exige uma ofensa de alguma gravidade aos bens jurídicos protegidos, pois nem sempre qualquer ofensa a esses bens ou interesses é suficiente para configurar o injusto típico. Segundo esse princípio que Klaus Tiedemann chamou de princípio de bagatela, é imperativa uma efetiva proporcionalidade entre a gravidade da conduta que se pretende punir e a drasticidade da intervenção estatal. Amiúde, condutas que se amoldam a determinado tipo penal, sob o ponto de vista formal, não apresentam nenhuma relevância material. Nessas circunstâncias, pode-se afastar liminarmente a tipicidade penal porque em verdade o bem jurídico não chegou a ser lesado" (TRATADO DE DIREITO PENAL - Parte Geral 1, 21ª edição, 2015, Ed. Saraiva, página 60).

Com é sabido, as normas se baseiam em princípios, que são valores fundamentais e nos quais se inspiram o ordenamento jurídico.

Segundo GUILHERME DE SOUZA NUCCI, ao tratar do princípio da intervenção mínima ou da subsidiariedade, sustenta que por este princípio o direito penal não deve interferir em demasia na vida do indivíduo e que a lei penal não deve ser vista como a primeira opção do legislador para compor os conflitos existentes na sociedade. E em complemento, ao discorrer sobre o princípio da fragmentariedade, que se traduz num corolário da intervenção mínima, assevera: "significa que nem todas as lesões a bens jurídicos protegidos devem ser tuteladas e punidas pelo direito penal, pois este constitui apenas uma parte do ordenamento jurídico. Fragmento é apenas a parte de um todo, razão pela qual o direito penal deve ser visto, no campo dos atos ilícitos, como fragmentário, ou seja, deve ocupar-se das condutas mais graves, verdadeiramente lesivas à vida em sociedade, passíveis de causar distúrbios de monta à segurança pública e à liberdade individual. O mais deve ser resolvido pelos outros ramos do direito, através de indenizações civis ou punições administrativas" (CÓDIGO PENAL COMENTADO, 16ª edição, 2016, Ed. Forense, páginas 14/15).

E em relação a crimes ambientais, o mesmo autor sustenta que "não há dúvida de que a proteção ao meio ambiente é de interesse geral da coletividade, porém, tal perspectiva não elide a possibilidade de se encontrar uma infração de ínfimo potencial ofensivo, cujo alcance é estreito e limitado" (Leis Penais e Processuais Penais Comentadas. Volume 2, 8ª ed., Forense, RJ, 2014, p. 548).

De acordo com a orientação traçada pelo Supremo Tribunal Federal, a aplicação do princípio da insignificância exige, para tal desiderato, cumulativamente, os seguintes requisitos: ofensividade mínima da conduta do agente; ausência de periculosidade social da ação; reduzido grau de reprovabilidade do comportamento do agente; e, inexpressividade da lesão jurídica provocada (Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 103.552-DF).

Mesmo que presentes tais requisitos, o fato só se torna atípico em situações especiais, dependendo das peculiaridades reveladas no caso concreto, para o reconhecimento do ilícito de bagatela. Caberá ao juiz, diante das circunstâncias do caso, analisar a verificação da insignificância, atentando especialmente para a ofensa experimentada pelo objeto jurídico protegido.

Seguindo essa orientação o Superior Tribunal de Justiça tem reconhecido a possibilidade de aplicação do princípio da insignificância para determinados casos, nos quais o fato objeto deste processo se enquadra perfeitamente.

Assim tem sido decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, como no julgamento do AgRg no HC nº 519.696-SC, relator Min. Jorge Mussi, saber:

"AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME AMBIENTAL.....

1. A aplicação do princípio da insignificância, causa excludente de tipicidade material, admitida pela doutrina e pela jurisprudência em observância aos postulados da fragmentariedade e da intervenção mínima do Direito Penal, demanda o exame do preenchimento de certos requisitos objetivos e subjetivos exigidos para o seu reconhecimento, traduzidos no reduzido valor do bem tutelado e da favorabilidade das circunstâncias em que foi cometido o fato criminoso e de suas consequências jurídicas e sociais.
2. Esta Corte admite a aplicação do referido postulado aos crimes ambientais, desde que a lesão seja irrelevante, a ponto de não afetar de maneira expressiva o equilíbrio ecológico, hipótese caracterizada na espécie".
- 3.- Na hipótese, em que o agravante foi flagrado mantendo em cativeiro 4 pássaros da fauna silvestre, das espécies tico-tico, papa-banana e coleiro, estão presentes os vetores de conduta minimamente ofensiva, ausência de periculosidade do agente, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e lesão jurídica inexpressiva, os quais autorizam a aplicação do pleiteado princípio da insignificância, haja vista o

vasto lastro probatório constituído nas instâncias ordinárias.

4.- Agravo regimental desprovido".

Existem outras decisões do Superior Tribunal de Justiça, a saber:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME AMBIENTAL. AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. APLICAÇÃO.

1. A aplicação do princípio da insignificância, causa excludente de tipicidade material, admitida pela doutrina e pela jurisprudência em observância aos postulados da fragmentariedade e da intervenção mínima do Direito Penal, demanda o exame do preenchimento de certos requisitos objetivos e subjetivos exigidos para o seu reconhecimento, traduzidos no reduzido valor do bem tutelado e na favorabilidade das circunstâncias em que foi cometido o fato criminoso e de suas consequências jurídicas e sociais. 2. Esta Corte admite a aplicação do referido postulado aos crimes ambientais, desde que a lesão seja irrelevante, a ponto de não afetar de maneira expressiva o equilíbrio ecológico, hipótese caracterizada na espécie. 3. Na hipótese, estão presentes os vetores de conduta minimamente ofensiva; ausência de periculosidade do agente; reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e lesão jurídica inexpressiva, os quais autorizam a aplicação do pleiteado princípio da insignificância, haja vista o vasto lastro probatório constituído nas instâncias ordinárias. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AgRg no REsp 1815966/PR, Min. JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 22/10/2019, DJe 08/11/2019 - grifo nosso).

Da Sexta Turma, confira-se:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME AMBIENTAL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. APLICABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS ESPECÍFICAS DO CASO CONCRETO AUTORIZADORAS. AGRAVO DESPROVIDO.

1. O Supremo Tribunal Federal, no exercício de sua jurisdição constitucional, consagrou o entendimento de que, para a aplicação do princípio da insignificância, devem estar presentes, cumulativamente, as seguintes condições objetivas: a) mínima ofensividade da conduta do agente; b) nenhuma periculosidade social da ação; c) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento do agente; e d) inexpressividade da lesão jurídica provocada. Preenchidos todos esses requisitos, a aplicação desse princípio possui o condão de afastar a própria tipicidade penal, especificamente na sua vertente material, entendimento esse sufragado por este Tribunal Superior. 2. Estando expressamente consignado, no acórdão proferido pelo Tribunal de origem, que a conduta levada a efeito pelo agente não teve o condão de causar efetivo risco às oito espécies (canários-da-terra) apreendidas e ao ecossistema, é pertinente a aplicação do princípio da bagatela própria. 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 1269973/GO, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 11/12/2018, DJe 01/02/2019)

No mesmo sentido são alguns julgados do Supremo Tribunal Federal:

AÇÃO PENAL. Crime ambiental. Pescador flagrado com doze camarões e rede de pesca, em desacordo com a Portaria 84/02, do IBAMA. Art. 34, parágrafo único, II, da Lei nº 9.605/98. Rei furtiva de valor insignificante. Periculosidade não considerável do agente. Crime de bagatela. Caracterização. Aplicação do princípio da insignificância. Atipicidade reconhecida. Absolvição decretada. HC concedido para esse fim. Voto vencido. Verificada a objetiva insignificância jurídica do ato tido por delituoso, à luz das suas circunstâncias, deve o réu, em recurso ou habeas corpus, ser absolvido por atipicidade do comportamento. (HC 112563, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Relator(a) p/ Acórdão: Min. CEZAR PELUSO, Segunda Turma, julgado em 21/08/2012, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-241 DIVULG 07-12-2012 PUBLIC 10-12-2012 - grifei).

CRIME - INSIGNIFICÂNCIA - MEIO AMBIENTE. Surgindo a insignificância do ato em razão do bem protegido, impõe-se a absolvição do acusado. (AP 439, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 12/06/2008, DJe-030 DIVULG 12-02-2009 PUBLIC 13-02-2009 EMENT VOL-02348-01 PP-00037 RTJ VOL-00209-01 PP-00024 RT v. 98, n. 883, 2009, p. 503-508 - grifei).

Neste caso, como já visto, o réu abateu, se é que seja, apenas uma capivara, para servir de alimento. Não se trata de espécie ameaçada. Ao contrário, porque se trata de animal que se prolifera com facilidade e que promove a destruição por onde passa. O abate verificado não causou concretamente nenhuma lesividade ao bem ambiental tutelado pela norma, não afetou a ordem social e de forma alguma desestabilizou o ecossistema.

Portanto, presentes na hipótese todas as circunstâncias que a Suprema Corte recomenda para a aplicação do princípio da insignificância que são a mínima ofensividade da conduta do agente, a ausência de periculosidade social da ação, o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica provocada.

Assim a conduta do réu, em relação ao crime ambiental, deve ser considerada atípica, impondo-se a sua absolvição.

No que respeita ao crime de porte ilegal de arma de fogo, de fato o réu estava portando uma espingarda, que foi utilizada no abate do animal.

Essa espingarda, que está identificada no laudo de exame pericial de fls. 131/133, estava com seus mecanismos em pleno funcionamento, comprovando-se a sua potencialidade lesiva. Por conseguinte, materialidade demonstrada.

Igualmente certa a autoria, porque o réu confessou o porte da arma e suas declarações estão confirmadas nos depoimentos dos policiais ouvidos.

E para a caracterização desse crime, que é de natureza formal, não se perquire qual seria o objetivo do porte. Basta verificar a inexistência de autorização para ter consigo a arma, o que ocorreu na espécie. Configurado o delito, acolhe-se nesta parte a denúncia com a consequente condenação do réu.

Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE EM PARTE A DENÚNCIA. De início, com fundamento no artigo 386, III, do CPP, absolvo o réu do crime do artigo 29, "caput", c. c. o § 4º, inciso V, da Lei nº 9.605/98. Em segundo lugar, passo a fixar a pena do réu quanto ao crime de porte ilegal de arma de fogo. Observando todos os elementos formadores do artigo 59 e 60, do Código Penal, não encontro razões suficientes para elevar a pena-base, que fica estabelecida no mínimo, ou seja, em dois anos de reclusão e 10 dias-multa, no valor mínimo. Sem alteração na segunda fase porque mesmo presente a agravante da reincidência (fls. 290/291), existe em favor do réu a atenuante da confissão espontânea, impondo-se a compensação das circunstâncias.

A condenação que o réu possui, que é específica, é por crime acontecido há mais de quatorze anos, tendo ocorrido a extinção da pena somente agora (fls. 290), daí o reconhecimento da reincidência. E como a reincidência ocorreu por crime da mesma espécie, sendo específica, impossibilitaria a substituição da pena restritiva de liberdade por restritiva de direito e, de certa forma, também prevê regime mais severo do que o aberto. A rigor, a letra fria da lei levaria o réu à prisão.

Considero tal medida desproporcional à ação praticada. Se a condenação anterior tivesse sido por crime diferente, ainda que mais grave, como exemplo um roubo, estupro, tráfico, etc., a reincidência não seria pelo mesmo crime e a substituição poderia acontecer, nos termos do artigo 44, § 3º, do CP.

Assim, a despeito de a reincidência ter se operado pela prática do mesmo crime, volto a dizer cometido o primeiro há mais de quatorze anos, é socialmente recomendável que o réu cumpra a pena aqui imposta em liberdade, prestando serviços à comunidade, porque preso, além de nada contribuir para a finalidade da pena, que é a reprovação e prevenção do crime cometido, constitui pesado ônus para o Estado. O réu não demonstra periculosidade, é trabalhador, com endereço certo e profissão definida. Mandá-lo para o cárcere é dar-lhe uma boa escola na arte de delinquir.

Portanto, por ser mais adequado, proporcional à ação delituosa cometida e até benéfico para a sociedade, delibero aplicar o disposto no artigo 44 do Código Penal e substituir a pena restritiva de liberdade por uma restritiva de direito, de prestação de serviços à comunidade, e outra pecuniária, de multa.

Condeno, pois, CARLOS ALEXANDRE GONÇALVES DA ROCHA, à pena de 2 (dois) anos de reclusão e dez dias-multa, no valor mínimo, substituída a primeira por uma pena restritiva de direito de prestação de serviços à comunidade, pelo mesmo tempo, e outra de multa, consistente em 10 dias-multa, no valor mínimo, por ter transgredido o artigo 14, "caput", da Lei nº 10.826/03.

Quanto ao regime de pena, diante das peculiaridades mencionadas e seguindo a tese acolhida pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, com voto do Ministro Roberto Barroso no HC 123.108/MG, que estabeleceu "(...) ii na hipótese de o juiz da causa considerar penal e socialmente indesejável a aplicação do princípio da insignificância por furto, em situações em que tal enquadramento seja cogitável, eventual sanção privativa de liberdade deverá ser fixada, como regra geral, em regime inicial aberto, paralisando-se a incidência do art. 33, § 2º, 'c', do CP no caso concreto, com base no princípio da proporcionalidade", que tem correlação próxima com este julgamento, estabeleço para o réu o regime aberto.

Sendo beneficiário da assistência judiciária gratuita, deixo de impor obrigação de pagamento da taxa judiciária.

P. I. C.

São Carlos, 13 de dezembro de 2022.

ANTONIO BENEDITO MORELLO

JUIZ DE DIREITO

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA